

0006317-47.2015.8.26.0306

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 374/2015 - Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO EL AOUAR DA FE

Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Terceira Principal << Informação indisponível >>

Artigo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,

José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0006317-47.2015.8.26.0306

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 374/2015 - Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO EL AOUAR DA FE

Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Terceira Principal << Informação indisponível >>

Artigo da Denúncia:

*

Aos 20 de julho de 2022, às 14:30 horas, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, onde presente se encontrava a Exma. Senhora Doutora NATÁLIA BERTI, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeado. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, verificou-se a presença do I. Representante do Ministério Público, DR. CÉSAR BOCUHY BONILHA. Ausente o(a) acusado(a) GUSTAVO EL AOUAR DA FÉ. Presente seu(sua) defensor(a) nomeado(a) DR(A). MARCELA MALTAROLO - OAB/SP 381.049. Em seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) GUSTAVO CALLIARI BONSEMBIANTE, PAULO HENRIQUE DEMARCHI. ADVERTÊNCIA: Excepcionalmente e em razão da

pandemia COVID-19, considerando a necessidade de dar celeridade à tramitação dos processos, esta audiência de instrução foi realizada por videoconferência. O Juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim. A audiência foi gravada em sistema audiovisual e será armazenada no programa SAJ, junto a este termo, sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do artigo 405 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Digam as partes acerca de eventual diligência cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados na presente instrução. Em seguida, pelo I. Dr. Promotor foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) acusado(a) foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito que: Declaro encerrada a instrução. Em seguida, o Dr. Promotor manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, o(a) Dr(a). Defensor(a) manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi proferida a sentença publicada em audiência:

Vistos.

GUSTAVO EL AOUAR DA FÉ, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c.c. artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 24 de agosto de 2015, por volta das 23h15min, na rodovia BR 153, na altura do km 98, próximo ao pedágio, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, GUSTAVO EL AOUAR DA FÉ, qualificado às fls. 199, agindo em concurso de agentes com indivíduo não identificado, transportava, para fins de tráfico, 89,720 kg (oitenta e nove quilogramas e setecentos e vinte gramas) de Cannabis sativa Linneu, conhecido como maconha, na forma do vegetal prensado e seco, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (cf. laudo de exame químico toxicológico de fls. 61/64). Segundo se apurou, o denunciado, que é oriundo do Estado de Goiás, transportava grande quantidade de maconha em um veículo VW Saveiro, cor vermelha, de placas ONY5303 Goiânia/GO, quando, no local supra, foi surpreendido com a ordem de parada de policiais rodoviários federais que faziam uma operação próximo ao pedágio. GUSTAVO ignorou o sinal e empreendeu fuga em direção a cidade de São José do Rio Preto.

Consta que após breve acompanhamento, o denunciado perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um poste de luz, evadindo-se do local. Em vistoria no veículo, os Policiais encontraram um Smartphone Motorola, capa rosa, com dois chips, desbloqueado, e uma CTPS em nome do denunciado. O aparelho de telefonia celular localizado no interior do veículo foi submetido à perícia técnica, laudo acostado às fls. 107/114. Os dados extraídos foram analisados conforme relatório de análise de fls. 126/131, restando estabelecido um liame entre o número do terminal telefônico e a conta da rede social Facebook usada pelo denunciado, sendo ele a pessoa da foto de fls. 119 (Facebook) e 170 (Detran). O denunciado, preso em flagrante, posteriormente, pela prática de tráfico de drogas e receptação (cf fls. 189/195), negou a prática delitiva. A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2019 (fls. 293/294). O acusado foi notificado (fl. 267), e apresentou sua defesa preliminar (fls. 287/288).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado.

O Ministério Público pediu a condenação, nos termos da denúncia.

O defensor pediu a absolvição do réu.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a

serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal punitiva é IMPROCEDENTE.

A materialidade delitiva do crime evidencia-se pelo inquérito policial (fl. 01), termo de depoimento (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo pericial (fls. 13; 61/64; 90/96; 107/114), documentos de instauração e apreensão (fls. 19/21; 39; 44/45; 80; 85/88; 117/118; 189/195; 235), termo de declarações (fls. 47/51; 146/147; 188), auto de incineração (fl. 120), auto de qualificação e interrogatório (fls. 221/224), relatório final (fls. 227/230), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

No entanto, a autoria não ficou comprovada, com absoluta certeza, pelas provas produzidas em audiência. Vejamos.

Paulo Henrique Demarchi (testemunha de acusação) disse que a região tem várias ocorrências de tráfico. No caso, o veículo empreendeu fuga. Ele entrou em um posto de combustível, achanado que era uma saída, ocasião em que colidiu com um poste. Um dos indivíduos empreendeu fuga e o outro ficou, tendo sido apresentada à Polícia Federal de São José do Rio Preto. Não conhecia a pessoa que ficou detida. Tinham informações do horário, por passar muito tráfico de drogas.

Gustavo Calliari Bonsembiante (testemunha de acusação) declarou que estavam em operação na região de José Bonifácio. Naquela noite, estavam no pedágio e deram ordem de parada para um veículo saveiro. Ele passou o pedágio e acelerou, fugindo. Realizaram acompanhamento tático e, após 3 Km, encontraram o veículo batido, abandonando-o no local. Na caçamba, encontraram malas com drogas. Dentro do veículo, encontraram um documento e um aparelho celular. A substância era maconha e eram 90kg. Foi feita a apreensão de um documento e de um aparelho celular. Estavam em dois no veículo. Quando chegaram, as duas pessoas tinham se evadido a pé. Era de noite e o local tinha mato. Fizeram buscas, mas não localizaram ninguém. Não se lembra se era carteira de trabalho ou outro documento. Fizeram a entrega da substância na Polícia Federal, em São José do Rio Preto, além dos objetos. Acredita que a polícia Federal prosseguiu com as investigações. Não se recorda se a placa era de outro Estado. Na época, estava acontecendo a festa do peão e o condutor do veículo estava com o chapéu grande. Fizeram a pesquisa da propriedade do veículo, mas não se recorda se pertencia à pessoa, cujo documento que foi encontrado.

Gustavo El Aouar da Fé (réu) disse que é casado. Tem 4 filhos, 01 ano e 08 meses, 04 anos (gêmeos) e 07 anos. Eles moram com a mãe. Faz tempo que não trabalha. O pai é autônomo e a mãe é merendeira do colégio. Tem outros processos, de furto, receptação, por uso e um tráfico. Declarou ter parado de usar drogas e ingerir bebidas. É evangélico. Sobre os fatos, disse não conhecer as testemunhas. Alegou que nunca esteve em São José do Rio Preto. Os indivíduos Rafael Miranda e Lucas Vidal tinham uma saveiro vermelha. Andou e usou entorpecentes no veículo, podendo ter esquecido a carteira dentro do carro. Não perdeu o celular. Perdeu a carteira de trabalho, e somente percebeu em 2017, quando não achou a carteira, após arrumar o novo emprego. Tirou nova carteira de trabalho em 2017. Rafael Miranda e Lucas Vidal eram do seu bairro. Eles vendiam drogas. Na época, era usuário. Na época, roubava para vender os objetos para eles e comprar droga. Eles tinham uma saveiro, mas não sabe se esse carro. Fez boletim de ocorrência em Nova Crixás, quando perdeu seus documentos.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são insuficientes para fundamentar um decreto condenatório.

Na fase extrajudicial, o réu negou a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Declarou que: "confirma ser o titular da CTPS de fls. 13 dos autos; QUE nunca foi o titular das linhas telefônicas citadas no quesito 3; QUE nunca utilizou o veículo ONY-5303; QUE no ano de 2015/2016 trabalhava no CEASA em Goiânia; QUE nunca esteve na cidade de José Bonifácio; QUE nunca saiu de Goiás, à exceção dos limites territoriais com Mato Grosso; QUE não conhece CLEONICE FRANCISCA DA SILVA; QUE indagado acerca do motivo pelo qual sua carteira de trabalho encontrava-se no interior do veículo, o declarante informa que referido documento foi extraviado em 2016; QUE registrou o extravio de sua CTPS perante a

Polícia Civil via Sistema Eletrônico de Informação; QUE não tem relação com a droga apreendida nos autos; QUE nega que tenha transportado drogas, embora afirme ser usuário de maconha; QUE o declarante informa que já foi empregado da GYN VIDROS TEMPERADOS LTDA; QUE o declarante não dispõe de boletim de ocorrência da Polícia Civil de Goiás, que informa o extravio de sua CTPS" (fl. 188).

Em juízo, novamente, o acusado negou os fatos.

A negativa do réu não pode ser afastada, com absoluta certeza, pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Isto porque, nenhuma das testemunhas em juízo confirmou ter visto o acusado no interior do veículo ou que o réu era a pessoa que fugiu na data da abordagem.

Ainda, embora tenham sido encontrados documentos do acusado dentro do carro, tal fato não é suficiente para demonstrar que o réu estava dentro do veículo naquela data, realizando o transporte das substâncias entorpecentes. Aliás, ouvido em juízo, o acusado informou que perdeu os documentos, inclusive a carteira de trabalho. De fato, Gustavo registrou a perda/extravio de sua carteira de trabalho em 27/01/2016 (fls. 171/172), cinco meses depois de o documento ter sido encontrado no interior do veículo Saveiro (fls. 190/191). No entanto, tais indícios não demonstram, efetivamente, que o réu estava no carro e transportava a droga. Ora, o ônus probatório não pode ser invertido em seu desfavor.

Soma-se a isso que, o laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido (fls. 117/118) não trouxe qualquer informação relevante ou suficiente para esclarecer a autoria do delito. Aliás, a proprietária do celular apreendido, Janete Vitaliva Teixeira, declarou não conhecer Gustavo El Aouar da Fé (fl. 132).

Já o relatório de investigações de fls. 126/131 identificou o número (62)

994835414, associado ao perfil "KRA DO BENEFÍCIO", na rede social Facebook.

Todavia, conforme informação de fl. 131, a baixa resolução das fotos de capa e do perfil não permitiram a identificação do usuário da página, não sendo possível presumir que se trata do acusado apenas pela coincidência na data de nascimento. Ainda que assim não o fosse, consoante já afirmado, a presença de seus documentos pessoais no veículo não comprova, de forma indene de dúvidas, que o réu realmente estava no carro naquela data.

E não é só. A proprietária registral do veículo apreendido (Cleonice Francisca da Silva), ouvida apenas durante o inquérito policial, afirmou que o veículo foi vendido por seu esposo André Luís e declarou não conhecer o acusado (fls. 47/48). Por sua vez, André Luís confirmou ter vendido o veículo para uma pessoa chamada Paulo César e, da mesma forma, afirmou não conhecer o acusado Gustavo (fls. 49/51). Portanto, o que se tem são meros elementos informativos e indícios, os quais não foram corroborados durante a fase de instrução processual. Não foi possível confirmar que o réu estava no veículo e, menos ainda, que as drogas pertenciam ao acusado e/ou que ele participava do transporte/comercialização ilícita. As provas colhidas sobre a égide do contraditório não permitem inferir a responsabilidade penal do réu. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de fazer prova robusta a autorizar o decreto condenatório. A suspeita e a dúvida não bastam e, se dúvida houver, esta é valorada em favor do acusado, em razão do princípio do estado de inocência.

Importante destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, caput, prevê o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado irá analisar o caso e julgá-lo conforme as provas trazidas aos autos, mas terá discricionariedade para a sua valoração, distinguindo-se, portanto, do princípio da convicção íntima e da prova tarifada. Conforme assinala Guilherme de Souza Nucci:

"(...) a persuasão racional é o método misto, também chamado de convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada, ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), significando permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato (NUCCI, 2008, pag. 339).

Todavia, a segunda parte do artigo 155, caput, CPP, estabelece que a decisão judicial não pode ser fundamentada, em regra, exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, os elementos probatórios colhidos em sede policial precisam ser confirmados pelas provas produzidas através da dilação probatória realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, não houve a comprovação dos fatos na fase judicial. Assim, os depoimentos apresentados são suficientes para gerar uma dúvida fundada. O conjunto probatório não se mostrou apto a embasar uma condenação contra o réu e a aplicação do princípio *in dubio pro reo*, a justificar uma absolvição, é medida que se impõe. Nesse sentido, são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"Apelação. Uso de documento falso. Absolvição por insuficiência de provas. Viabilidade. Ausência de exame pericial apto a comprovar a falsidade dos documentos. Elementos que não comprovam o conhecimento pela ré da suposta falsidade dos atestados, bem como de que os apresentou à empregadora nesta condição. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor da acusada. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio *in dubio pro reo*. Recurso provido." (Apelação 0056565-41.2011.8.26.0602. Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Sorocaba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 08/03/2016. Data de registro: 10/03/2016).

"Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Corréu que assumiu isoladamente a propriedade dos entorpecentes. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio *in dubio pro reo*. Recurso provido." (Apelação 0000062-31.2013.8.26.0278. Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Itaquaquecetuba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/06/2016. Data de registro: 14/06/2016).

"HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DÚVIDAS QUANTO À REAL RESPONSABILIDADE DO RÉU NA PROVOCAÇÃO DO ACIDENTE – POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do *in dubio pro reo*. RECUSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO." (Apelação 0005445-33.2012.8.26.0566. Relator(a): Willian Campos. Comarca: São Carlos. Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/04/2016. Data de registro: 18/04/2016).

Ressalte-se, uma vez mais, que a autoria se mostrou duvidosa, pois a condenação não pode se fundamentar em juízo de probabilidade. Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital do homem, isto é, a sua liberdade. Logo, na dúvida, a garantia da liberdade sempre deve prevalecer sobre o poder punitivo estatal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para ABSOLVER GUSTAVO EL AOUAR DA FÉ, portador do R.G. n.º 5.940.244, filho de Carlos Antônio Pereira da Fé e Muna Rachid El Aouar, nascido em 14/04/1993 em Goiânia/GO das acusações previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.

Após a prolação da sentença, foram questionadas as partes acerca do interesse em recorrer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que requeiro vista para apresentação das razões de apelação. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi

dito que: Concedo o prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões de apelação, Em seguida abra-se vista a defesa para apresentação de contrarrazões. Pela Defensora foi dito que aguardará a intimação do réu para manifestar-se acerca da interposição ou não de recurso. Saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Augusto César Cristal Lopes, matrícula 358.518, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.